



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

così composta:

Dott. Ettore Capizzi

Presidente

Dott.<sup>ssa</sup> Lucia Fanti

Consigliere

Dott. Nicola Saracino

Consigliere Relatore

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello iscritta al **numero 2519 del ruolo generale** degli affari contenziosi dell'**anno 2016**, trattenuta in decisione all'udienza del giorno **08/07/2020**, vertente

**TRA**

*Parte\_1* (c.f. *P.IVA\_1* ),  
difesa dall'Avv. GHIA LUCIO (c.f. *C.F.\_1* )

**APPELLANTE**

**E**

*CP\_1* (c.f. *P.IVA\_2* ),

**APPELLATA**

**E**

*Controparte\_2* (c.f. *C.F.\_2* ),  
dall'Avv. INDACO GIANLUCA (c.f. *C.F.\_3* ),

**APPELLATO**

**E**

*Controparte\_3* (c.f. *C.F.\_4* ) difesa  
dall'Avv. INDACO GIANLUCA (c.f. *C.F.\_3* ),

**APPELLATA**

**OGGETTO:** appello contro la sentenza n. 20337/2015 resa in data 8 ottobre 2015 dal Tribunale di Roma.

**Conclusioni dell'appellante:** “Voglia codesta ill.ma Corte, in riforma integrale della sentenza n. 20337/2015, n. cron. 7554/2015, rep. n. 21466/2015, non notificata, resa dal Tribunale Civile di Roma, Giudice Unico Dott.ssa M. Buscema, pronunciata all'udienza dell'8 ottobre 2015 ai sensi dell'art. 281 *sexies* cpc, all'esito della causa iscritta in primo grado al n.r.g. 25861/2010:

-1) in via principale e nel merito, rigettare ogni domanda proposta dai Sigg.ri *Controparte\_2* e *Controparte\_3* con l'atto di citazione

in opposizione a decreto ingiuntivo, siccome inammissibile e/o infondata e, comunque, non provata; 19

-2) per l'effetto, condannare i fideiussori, Sigg.ri [...] CP\_2 e Controparte\_3 a pagare in solido fra loro ed in favore della Parte\_1 la somma di Euro 200.000,00 o quella diversa somma eventualmente risultante dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi convenzionali dal 01.10.2009 sino all'effettivo e integrale soddisfo;

-3) in ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio, competenze ed onorari, oltre Iva e CPA, come per legge, condannando i medesimi fideiussori alla restituzione in favore dell'appellante delle somme di danaro che quest'ultima ha corrisposto pari ad Euro 7.743,50 a titolo di spese legali per capitale e interessi, oltre Iva, CPA e rivalutazione monetaria e sino al soddisfo.”

**Conclusioni degli appellati** CP\_2 e CP\_3 “Voglia la Corte rigettare il gravame con condanna dell'appellante alle spese del grado.”.

## FATTO E DIRITTO

Con sentenza appellata era stata accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo di euro Euro 263.767,60 contro la CP\_1 ed i signori Controparte\_2 e Controparte\_3 quali garanti.

Nell'accogliere l'opposizione il giudice di prime cure, qualificata la garanzia prestata alla stregua di una fideiussione e non già di un contratto autonomo di garanzia, aveva rilevato la mancanza delle dovute certificazioni imposte dall'art. 50 TUB per conferire valore di prova alle scritture contabili esibite dalla Pt\_1 a sostegno del proprio credito.

Con l'appello viene contestata tale “imperfezione” delle scritture contabili che sono state nuovamente depositate in questa sede complete della certificazione, così come erano già state depositate nel fascicolo di parte della fase monitoria ma, per dimenticanza, non nella fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo.

Si tratta in particolare delle scritture relative al conto corrente n. 003007 dalle quali risulta un credito della Pt\_1 di 200.000 euro oltre interessi convenzionali dal 1°ottobre 2009 sino all'effettivo e integrale soddisfo.

Documenti che costituirebbero prova del credito nei confronti dei garanti poiché il contratto dagli stessi sottoscritto configura una garanzia autonoma e non una fideiussione, ciò desumendosi sia dalla limitazione

della facoltà di proporre eccezioni, sia dalla clausola che eleva le scritture contabili della banca al rango di prova contro i garanti.

Si sono costituiti in appello i soli fideiussori *Controparte\_2* e *Controparte\_3* chiedendo il rigetto dell'impugnazione e riproponendo, senza farne oggetto di specifico appello incidentale, i motivi di merito a base dell'opposizione a decreto ingiuntivo non scrutinati dal primo giudice e consistenti: nella violazione dell'art. 1845 c.c. sia per la mancata indicazione del termine previsto dal secondo comma della norma, sia comunque per l'inesistenza di una giusta causa; la nullità delle clausole contrattuali stipulate inter partes relativamente: 1) alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, 2) alla commissione di massimo scoperto, 3) alla determinazione del tasso degli interessi.

L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 08/07/2020, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.

L'appellante sostiene, in questo grado, la tesi secondo cui quello intercorso coi signori *CP\_2* e *CP\_3* non fosse un contratto di fideiussione bensì un contratto autonomo di garanzia, al fine di rendere vevoli come prova nei loro confronti le scritture contabili - non esaminate in prime cure - sulla base di specifica clausola contrattuale. Ciò, peraltro, senza fare oggetto di impugnazione la sentenza di primo grado nella parte in cui ha qualificato il rapporto alla stregua della fideiussione, opzione non irrilevante essendone disceso il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata in quella sede dagli odierni appellati che si proclamavano "consumatori" invocando il relativo foro.

Come recentemente osservato da Cass. Civ., **sez. I, 21/01/2020, n.1186, le due figure** giuridiche - quella della fideiussione e quella del contratto autonomo di garanzia - sono difforni sia sul piano della causa che degli effetti del negozio, ciò principalmente per la mancanza di accessorietà della garanzia autonoma in riferimento al debito garantito e quindi al regime di eccezioni opponibili dal garante e dal debitore garantito nei confronti del beneficiario.

La giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010) chiarisce che il contratto autonomo di garanzia serve a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile contrariamente al contratto del fideiussore il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui;

quindi il contratto autonomo di garanzia trasferisce, in concreto, da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.

E' proprio l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorialità che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, cit. supra; v. anche Sez. 3, Sentenza n. 22233 del 20/10/2014), restando salva la sola facoltà del garante di ricorrere al rimedio generale dell'"exceptio doli" (Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 31956 del 11/12/2018).

Pertanto alla qualificazione giuridica della garanzia prestata come fideiussione ovvero come contratto autonomo di garanzia sono collegate conseguenze rilevanti in ordine al regime di opponibilità delle eccezioni sollevabili dal garante e dal debitore principale ed anche in punto di competenza per territorio laddove il garante sia un consumatore.

Ciò premesso deve tuttavia rilevarsi che gli appellati non hanno riproposto espressamente l'eccezione di incompetenza per territorio, così incorrendo nella decadenza dell'art. 346 cpc che riguarda, per l'appunto, domande ed eccezioni in senso proprio non riproposte in sede di appello, risultandone indenni solo le mere argomentazioni giuridiche, ovvero le questioni di fatto e di diritto addotte a sostegno delle medesime, che devono viceversa ritenersi implicitamente richiamate con la semplice istanza di rigetto dell'impugnazione da parte dell'appellato. Il medesimo principio vale anche per la riconduzione di un rapporto ad una determinata norma o ad un fatto specifico, atteso che neppure in tal caso la mancata, espressa riproposizione della tesi difensiva implica rinuncia alcuna all'originario "petitum" sì come svolto in primo grado (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1277 del 21/01/2005).

Si tratta, allora, di stabilire se il sovvertimento del titolo in base al quale la Pt\_1 pretende il pagamento integri un mutamento della *causa petendi* tale da determinare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 cpc.

Ritiene la Corte di dover rispondere affermativamente traendone argomentazione da Cass. civ., **sez. III, 17/02/2020, n.3893** secondo cui il potere qualificatorio del giudice d'appello che si sostanzia nel conferire al

rapporto controverso una qualificazione giuridica difforme da quella data dal primo giudice con riferimento all'individuazione della *causa petendi*, incontra il limite di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al suo esame (cfr. Cass. n. 12471/01, n. 26999/05, n. 7620/06) e di non mutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (cfr. Cass. n. 21484/07, n. 15383/10).

Nel caso di specie, la qualificazione giuridica del contratto di garanzia, così come suggerita dall'appellante, presuppone una nuova attività interpretativa del contratto in base a clausole contrattuali non considerate dal giudice di primo grado al fine di desumerne l'autonomia della garanzia. Attività che implica una modificazione del fatto costitutivo della pretesa di pagamento avanzata dalla <sup>Contro</sup> in quanto presupponente l'autonomia della garanzia, estranea al contratto tipico di fideiussione, azionato e sostenuto in primo grado e che comporta una *mutatio libelli*, inammissibile in grado d'appello.

L'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 345 cpc è il corollario del principio che limita il potere del giudice d'appello di qualificare il contratto oggetto del giudizio in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, quando alla nuova qualificazione si giunga prendendo in esame fatti nuovi e non dedotti dalle parti, nè rilevati dal giudice di primo grado. Pertanto, una volta che un contratto di garanzia sia stato qualificato come fideiussione tipica dal giudice di primo grado, per giunta in accoglimento della tesi della <sup>Pt\_1</sup> poi appellante, è viziata da ultrapetizione la sentenza con la quale il giudice d'appello lo qualifichi come contratto autonomo di garanzia, facendo leva sul contenuto di alcune clausole contrattuali non considerate dal giudice di prime cure (cfr. Cass. n. 2420/11; Cass. 10617/12).

L'appello merita, pertanto, di essere dichiarato inammissibile sia perché viola l'art. 345 cpc. sia perché - non essendo stata oggetto di specifica impugnazione - risulta coperta dal giudicato l'affermazione della natura di fideiussione del contratto intercorso tra le parti.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in base al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37. Devono compensarsi quelle nei confronti di <sup>CP\_1</sup> <sup>L...</sup>, contumace nel grado.

Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

**PER QUESTI MOTIVI**

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da  
Parte\_1 nei confronti di [...]  
Controparte\_5 Controparte\_3 , contro  
la sentenza indicata in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così  
provvede:

a) dichiara l'appello inammissibile;

b) condanna la Parte\_1 al rimborso, in favore di  
Controparte\_2 e di Controparte\_3 , difesi da  
unico Avvocato, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si  
liquidano in euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e  
accessori di legge, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario;  
compensa le spese nei confronti di CP\_1

— dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater* d.p.r. 30 maggio  
2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i  
presupposti per il versamento, da parte di Parte\_1  
[...] i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato  
pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma il giorno 16/11/2020.

Il Consigliere Estensore  
Dott. Nicola Saracino

Il Presidente  
Dott. Ettore Capizzi